

1527444-94.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... chutando a porta, falando que estava no tráfico. Não estava no tráfico. Estava deitado com sua mãe, no dia da sua folga. Trabalha no lava-rápido. O tráfico é na frente da sua casa mesmo. É do rapaz que ia ser testemunha, mas ele foi embora. Não pode ficar falando disso. Os policiais invadiram sua casa, falando que lá era onde ocorria o tráfico. Nunca foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527444-94.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527444-94.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2307242/2021 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 21328339 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 4035/21/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2307242 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALLACE QUEIROZ DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos

Wallace Queiroz de Jesus foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06 e artigo 180, "caput" do Código Penal c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" e artigo 69, "caput" do Código Penal, pois:

i) No dia 10 de novembro de 2021, por volta de 10h40, na Rua Cônego Antonio Pinto, 37, Pedreira, nesta cidade, WALLACE mantinha em depósito, para entregar ao consumo de terceiros, 7,1g de cocaína e 8,3g de "Cannabis sativa L.", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar;

ii) No mesmo local supra, entre o dia 28 de outubro de 2021, por volta de 22h45 e o dia 10 de novembro de 2021, por volta de 10h40, recebeu de terceiro, a placa FVG 7612, retirada da motocicleta Honda CB 250F, Twister, pertencente a Neilton Carneiro da Silva, ciente de que era produto de crime anterior.

O réu foi preso em flagrante delito e, no dia seguinte, teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 51/57).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 22 de novembro de 2021 (fls. 71/73).

O réu foi regularmente citado em audiência e apresentou resposta à acusação em audiência.

Em 16 de dezembro de 2021, foi a prisão preventiva do réu substituída por medidas cautelares, tendo sido expedido alvará de soltura (fls. 129/131).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes e absolvição pelo delito de receptação, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito e falta de provas no segundo crime. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da menoridade relativa, afastamento da qualificadora de estado de calamidade, aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e recurso em liberdade.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), pelo laudo de exame toxicológico definitivo (fls. 145/146), pelo laudo da placa (fls. 89/94), pelo laudo do selo de chassi (fls. 86/88), pelo boletim de ocorrência do crime anterior (fls. 23/24) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria do delito de tráfico de entorpecente foi comprovada. No entanto, a do crime de receptação é incerta.

A testemunha Mário Morano Martins, policial civil, relatou que receberam denúncia anônima e foram ao local, em viatura descaracterizada e outra caracterizada. Ficaram observando. Viu o réu saindo da casa dele. O réu saiu, ficou ali fora, conversou com um rapaz e voltou para dentro. Decidiram abordar o réu. O réu disse que o pacote estava dentro da casa. A mãe do réu apareceu e confirmou que o réu morava ali. Ela autorizou a entrada. Encontraram a droga num saquinho com estojo. Havia maconha e cocaína. Encontraram também placa e selo como produtos de roubo. O réu estava com um saco plástico. O réu serviu o rapaz e entrou de novo. Viu o réu com o saco plástico e com movimentação de tráfico, tirando algo da sacola e passando ao transeunte. O réu não falou nada sobre a placa. A placa e saquinho estavam jogados no chão. A mãe dele disse que aquele era o quarto do réu. A mãe do réu disse que não sabia de nada. Não encontraram dinheiro. Viu movimentação de troca. Viu o réu "tirando". Depois encontraram droga no saco. Não viu dinheiro. Uma outra equipe realizou outro flagrante ali no mesmo dia. Também era tráfico. Foram feitos muitos flagrantes ali.

A testemunha Elder Carlos Fonseca, policial civil, relatou que receberam denúncia anônima de tráfico de entorpecentes no endereço em questão. Foram ao local em uma viatura descaracterizada e outra caracterizada. Ficaram, quinze minutos e observaram movimentação. Viram, o réu com uma sacola na mão servindo alguém, em

movimento típico de tráfico. O réu, então, entrou em casa e saiu sem a sacola, motivo pelo qual foi abordado. O réu disse que morava ali. A mãe do réu apareceu e autorizou a entrada na residência. Explicaram a situação à mãe do réu. A mãe do réu acompanhou as buscas. No quarto, estava a sacola com as drogas. Havia também placa de motocicleta e chassi de outra moto. Esses itens constaram como produtos de furtos. Foram à delegacia com o réu e a mãe dele. As placas e selo de identificação estavam no quarto do réu. O réu não falava nada. A denúncia anônima mencionou endereço, mas não se lembra das características. Não houve outra pessoa abordada. Não se lembra da detenção de outra pessoa, nem mesmo de alguém conhecido por "sabonete".

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado negou a prática do delito. Tinha pego a placa da moto de um rapaz para colocar na bicicleta. Os policiais chegaram na sua casa, chutando a porta, falando que estava no tráfico. Não estava no tráfico. Estava deitado com sua mãe, no dia da sua folga. Trabalha no lava-rápido. O tráfico é na frente da sua casa mesmo. É do rapaz que ia ser testemunha, mas ele foi embora. Não pode ficar falando disso. Os policiais invadiram sua casa, falando que lá era onde ocorria o tráfico. Nunca foi preso ou processado anteriormente, exceto por atos infracionais, consistentes em furto e tráfico de drogas. É usuário de maconha. Pegou a placa na casa do menino e ia colocar na bicicleta, porque ia dar "um grau", para ficar raspando a placa, etc. Não tem tráfico dentro de sua casa. Pegaram outra pessoa e falaram que a droga era sua. Essa outra pessoa estava presa, mas foi solta. Eles pegaram a droga do menino, "jogaram" nele, depois pegaram droga que não era dele e "jogaram" no réu. A pessoa que era proprietária da droga estava presa, mas foi solta no dia anterior da audiência. Não sabia que a placa era produto de crime. Conseguiu ela na casa de um amigo seu. Não sabe do que se tratava a etiqueta do chassi. Nunca teve carro ou moto.

Pois bem. O réu não confessou a prática dos delitos.

Quanto ao crime de tráfico de substância entorpecente, tem o réu em seu desfavor, o auto de exibição e apreensão, documentos e laudos periciais acima referidos, além dos depoimentos colhidos em audiência, tudo confirmando a narrativa da denúncia, isto é, que policiais foram apurar notícia de tráfico na data e local dos fatos, tendo lá visto o réu retirar um pequeno volume de uma sacola e entregá-lo a um terceiro, motivo pelo qual decidiram abordar o réu minutos depois, em frente à sua residência, cuja entrada foi franqueada aos policiais. Lá, foram encontrados os entorpecentes acima descritos.

Confira-se o depoimento da testemunha Mário Morano Martins: "Viu o réu com o saco plástico e com movimentação de tráfico, tirando algo da sacola e passando ao transeunte".

Robora no mesmo sentido a narrativa da testemunha Elder Carlos Fonseca: "Viram, o réu com uma sacola na mão servindo alguém, em movimento típico de tráfico. O réu, então, entrou em casa e saiu sem a sacola, motivo pelo qual foi abordado. O réu disse que morava ali. (...) No quarto, estava a sacola com as drogas".

Na residência do acionado também foram encontrados selo de chassi e placa indicados à fls. 68, esta última objeto de furto anterior.

Como cediço, o tráfico de drogas é crime permanente, e está em flagrante quem o pratica em sua residência, ainda que para guarda ou depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, como no caso em apreço em que os agentes da lei viram o acionado em movimento típico de tráfico.

O que a jurisprudência cada vez mais considera inválido é o ingresso da polícia em

residência quando não ficar demonstrada a presença de elementos indicativos de causa provável, não se tolerando, por exemplo, a invasão de domicílio baseada apenas em denúncia anônima.

Neste momento é oportuno ressaltar que, ao contrário das afirmações do réu, a mãe do acionado franqueou a entrada dos policiais, inclusive acompanhou a ocorrência e foi ouvida em sede pré-processual, como se vê por fls. 06.

Invasão houvesse incumbiria à Defesa requerer a oitiva desta pessoa em Juízo, o que não ocorreu.

Existindo crime permanente (situação flagrancial), como anteriormente já mencionado, há de ser interrompido pelo Estado. Não há, portanto, que se falar, de plano, em nulidade de caráter absoluto e contaminação das provas obtidas mediante ingresso dos policiais no imóvel.

Impende consignar que o direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, não pode ser transformada em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam.

Ao contrário do sustentado pela defesa, o depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus 73518-5 - Relator: Ministro Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

E mais: " (...) VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus 73518/SP, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996).

Ainda: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 366258/MG, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014).

Considere-se, ainda, que em casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando

verdadeira lei do silêncio, razão pela qual desprezar os depoimentos policiais nesses casos implicaria em consagrar a total impunidade.

Por fim, pouco importa a inexistência de anotação, petrecho, celular, dinheiro, ou circunstância que pudesse indicar a prática da mercância. O crime de tráfico de entorpecentes, para sua tipificação, não exige a prova do elemento subjetivo do tipo.

Assim, quæstio a ser apreciada é a necessidade ou não de demonstração do fim de mercancia (traficância) para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes.

VICENTE GREGO FILHO (Tóxico prevenção-repressão São Paulo: Saraiva 8ª Ed. p. 98), analisando o crime na lei anterior, afirma que o tipo subjetivo do crime de tráfico não prevê o fim especial de agir, esgotando-se no dolo natural.

Neste sentido, o crime de tráfico de entorpecentes, em ambas as leis, é um tipo misto alternativo, onde a narrativa se ajusta ao que está entre as formas elencadas. Assim, as condutas de trazer consigo, guardar, transportar, etc. não exigem especial fim de agir.

Saliente-se, ademais, que o crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda.

Nesse sentido: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo Gomes RT 584/347).

Ainda: "TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com tóxicos acondicionados para venda Flagrante verificado enquanto tentava desvencilhar-se do entorpecente Prova segura da posse da substância e da materialidade Condenação mantida Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 212.768-3 Araçatuba 1ª Câmara Criminal Relator: David Haddad 11.08.97 V.U.)

Desta forma, o conjunto probatório, é idôneo a fundamentar a prática do delito de tráfico de substância entorpecente.

Quanto ao delito de receptação, malgrado o encontro de selo de chassi e placa veicular quando das diligências, mesmo, não tendo o réu apresentado nenhum documento ou justificativa plausível para a posse lícita de tal bem a prova é insuficiente para a condenação.

Nos termos do artigo 180 do Código Penal, não basta a possibilidade de o agente desconfiar da origem criminosa da coisa, pois, para a caracterização do delito é imprescindível o dolo direto, ou seja, o reconhecimento positivo de que se está mantendo situação ilícita decorrente de crime anterior.

No caso em apreço, verificada a dúvida a absolvição é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, primário, fixo a pena-base no

mínimo legal, totalizando cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

O crime foi praticado durante estado de calamidade pública, qual seja, a pandemia decorrente do COVID-19. Porém, o réu tem menos de vinte e um anos de idade. Assim sendo, sua pena não sofrerá alterações nesta fase. Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Saliento que o reconhecimento da agravante da prática de crime em ocasião de 'calamidade pública' é de natureza objetiva, bastando para sua incidência que o crime seja praticado nessa circunstância, sendo desnecessário provar que o agente tivesse intenção de valer-se de especial vulnerabilidade da vítima decorrente da situação.

De fato, a mens legis do dispositivo é justamente punir com mais rigor aquele que se determina à prática de crimes em período em que há maior vulnerabilidade social à prática delitiva e a vigilância das forças de segurança pública encontram-se em maior dificuldade de atuação ou repressão ao crime.

Em atenção ao artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, reduzo a pena do tráfico de entorpecentes em 2/3. Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

O acusado preenche os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, de modo que, nos termos do artigo 44, § 2º, do mesmo diploma, a pena privativa de liberdade será substituída - por igual lapso temporal - por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, que não goza de padrão de vida elevado, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço ABSOLVER o réu Wallace Queiroz de Jesus da acusação de prática do delito capitulado pelo artigo 180, caput, do Código Penal, com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e para declarar o réu Wallace Queiroz de Jesus como incurso no artigo 33, §4º, Lei 11.343/06, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade do réu por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a destruição do entorpecente e estojo apreendidos.

Com fundamento no artigo 122 e 123 do Código de Processo Penal, se decorridos 90 dias do trânsito em julgado desta decisão não forem reclamados o selo e placa apreendidos, decreto a perda deles em favor da União. Caso ausente valor econômico, fica autorizada a destruição.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA